

1528367-23.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... públicos. Nesse sentido: 'APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pleitos objetivando: a) fixação da pena base acima do mínimo legal; b) afastamento da figura do tráfico privilegiado; c) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) fixação do regime inicial fechado. 1. Condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1528367-23.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316419/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21508242 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 6263/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2316419 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON OTTENIO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

08/02/2022

Aos 8 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). DANIELA MOISÉS DA SILVEIRA FAVARO o(a) Dr(a). PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB 442123/SP, DEFENSOR(a) do ré(u) solto EMERSON OTTENIO DA SILVA (presente). Instalada a audiência, o Magistrado indagou o funcionário do CDP acerca do uso de algemas no réu, que por sua vez foram mantidas para fins de segurança, na medida em que o estabelecimento prisional conta com equipe insuficiente para manter a ordem, mormente diante da multiplicidade de audiências virtuais como regra realizadas simultaneamente. Ato contínuo foram ouvidas 02 testemunhas de acusação, os Policiais Militares MARCOS DE TADEU MORAES

PARESCHI e Leonardo Oliveira Santos e 05 testemunhas de Defesa, a saber, IVAN CARLOS DA SILVA, DARLY DE SOUZA PINTO, DIEGO COSTA PERES, CLAUDIA FERREIRA SILVA e LUCAS ROCHA BATISTA (todos já qualificados nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. Após conversar com sua Defesa, o(a) ré(u) foi interrogado(a) pelo sistema de áudio e vídeo. Na sequência, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, as quais afirmaram que não tinham outras diligências a serem realizadas e desistiam de eventuais pendentes, concordando com o encerramento da instrução. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. Pelo(a) Dr(a) Promotor(a), em debates orais, foi dito que: "Meritíssimo(a) Juiz(a), o réu EMERSON OTTENIO DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 14 horas, na Rua Marcondes Machado, n.º 3, Sapopemba, nesta Capital, forneceu e trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 95 tubos de eppendorf, contendo cocaína na forma de crack, com peso líquido de 15,92 gramas, 18 papélotes de cocaína sólida, com peso líquido de 19,9 gramas, 24 tubos de eppendorf, contendo cocaína em pó, com peso líquido de 4,2 gramas, e 42 invólucros de maconha, com peso líquido de 156,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais). A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 68). O réu foi devidamente citado (fls. 152) e apresentou defesa preliminar, por meio de defensor constituído (fls. 167/179). Na data de hoje, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. É o breve relatório. A denúncia deve ser julgada procedente. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e documentos que o acompanha, especialmente o boletim de ocorrência (fls. 5/9), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo pericial de constatação provisória (fls. 26/29) e laudo químico-toxicológico (194/197), bem como pela prova oral produzida. A autoria é indubitável. Está provado nos autos que EMERSON estava no local dos fatos, conhecido como ponto de prática delitiva de tráfico de drogas, portando duas sacolas plásticas, contendo os entorpecentes acima descritos, para fins de entrega a consumo de terceiros, até que policiais militares passaram pelo local em patrulhamento ostensivo. Ao ver os policiais, o denunciado, em atitude suspeita, começou a correr, razão pela qual os milicianos decidiram abordá-lo, alcançando-o e detendo-o. Em revista nas sacolas que EMERSON carregava foram encontrados 95 tubos de eppendorf com cocaína na forma de crack, 18 papélotes de cocaína sólida, 24 tubos de eppendorf contendo cocaína em pó e 42 invólucros de maconha. Já em poder do denunciado foi encontrada a quantia de R\$ 79,00 (setenta e nove reais). Questionado informalmente a respeito dos fatos, o denunciado confessou aos policiais que o valor era oriundo da venda de drogas. Formalmente interrogado em solo policial, EMERSON negou a prática delitiva, afirmando que é usuário de drogas (fl. 13). As circunstâncias da prisão, aliadas ao local da prisão em flagrante, à quantidade e variedade de entorpecentes, individualmente fracionados em pequenas porções, e ao dinheiro encontrado em trocados, demonstram que as drogas eram destinadas à entrega e ao consumo de terceiros. Em Juízo, EMERSON foi interrogado e disse que foi ao local para comprar cocaína, que guardou no bolso. Tinha em seu poder somente este papélot. Acredita que os traficantes se evadiram quando os policiais chegaram. A sacola com drogas estava nas proximidades. Na verdade, havia apenas um traficante, no final da viela, que deve ter se evadido pelo outro lado. Os policiais encontraram as drogas em um carro, logo a frente. O carro estava na rua, onde o interrogando estava. O traficante estava na outra ponta da viela, aos fundos. Não sabe porque os policiais disseram que as drogas estavam com o declarante. A testemunha Leonardo Oliveira Santos, policial militar, disse que estavam pela via Marcondes Machado quando visualizaram Emerson, que demonstrou nervosismo. Ele queria sair do lugar. Em revista pessoal, localizaram, dentro do bolso, maconha, crack e cocaína. Estavam dentro um saco plástico, dentro do bolso, em embalagens individuais. Havia dinheiro também. Havia R\$ 79,00. O dinheiro era trocado. Ele disse "perdi, perdi", bem como que somente iria se pronunciar em juízo. Ele não disse que era usuário. O local é conhecido como ponto de venda de

drogas. Não havia outras pessoas no local. A quantidade de drogas era razoável. Era uma sacola cheia. A testemunha Marcos Tadeu de Moraes Pareschi, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando visualizaram o acusado, que ficou assustado. Daí, a abordagem. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Fizeram a revista pessoal e localizaram drogas no bolso do acusado. Havia porções de crack, pino de cocaína, maconha, tudo embalado para venda. As porções estavam individualizadas. Havia R\$79,00 em dinheiro. O acusado disse “já era” e que somente iria se manifestar em juízo. O acusado portava apenas o entorpecente e o dinheiro. Não havia com ele petrechos para uso das drogas. As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, apenas confirmaram que o réu é usuário de drogas. Lucas afirmou que o réu é usuário de cocaína. Considerando todo o exposto, verifica-se que o conjunto probatório pré-processual restou suficientemente comprovado em juízo, sendo absolutamente apto a lastrear a sentença condenatória. Os policiais apresentaram versões coesas, dando conta de que EMERSON trazia com ele as drogas acima mencionadas. O réu alegou que as drogas estavam em um carro, estacionado na rua, mas o traficante ficava do outro lado da viela, sozinho!!! Ou seja, as drogas ficariam em local distante de onde estava o traficante, mas em local próximo ao acusado. A versão do acusado, portanto, não se sustenta. Destaca-se que gozam de importante credibilidade probatória os depoimentos dos agentes públicos, não havendo qualquer indício de que teriam razões para imputar à ré crime de forma injusta. Até porque nada levantou a Defesa a respeito de motivos pelos quais teriam que ser as palavras dos policiais recebidas com reservas. Insta ressaltar o entendimento consolidado do STJ no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 408808/PE HABEAS CORPUS 2017/0176479-0, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, em 03.10.2017), sendo que “inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova” (STJ, HC 418529 / SP HABEAS CORPUS 2017/0251727-2, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17/04/2018 A prova, pois, é robusta e autoriza a convicção de responsabilidade do acusado, nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a despeito da primariedade do réu (fls. 36/39), a pena-base deve ser fixada além do patamar mínimo legal, em claro atendimento aos comandos legislativos postos no art. 42, da Lei nº 10.343/06, em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas e do poder vulnerante das substâncias, em especial da cocaína e do crack. Repise-se que o réu foi encontrado em poder de relevante variedade de entorpecentes (95 tubos de eppendorf, contendo cocaína na forma de crack, com peso líquido de 15,92 gramas, 18 papéletes de cocaína sólida, com peso líquido de 19,9 gramas, 24 tubos de eppendorf, contendo cocaína em pó, com peso líquido de 4,2 gramas, e 42 invólucros de maconha, com peso líquido de 156,1 gramas). Como é cediço, apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, Acr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Habeas Corpus Criminal nº 2167456-43.2020.8.26.0000 -Voto nº 5 26/10/2017), de modo que a quantidade de droga apreendida poderia atingir inúmeros consumidores. Sem prejuízo, anoto a prejudicialidade específica da cocaína. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, foram consideradas a quantidade e a natureza da

droga apreendida (21,366kg de cocaína) para elevar a reprimenda básica, entendimento que se encontra de acordo coma jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 2. Não se pode considerar ilegal a elevação da pena-base na espécie, especialmente em se considerando que a ponderação das circunstâncias judiciais não

é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 516768 / RO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0178402-2, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 01.10.2019). Na segunda fase, nada a requerer Na terceira fase, nada a considerar. Anoto, contudo, que o réu não faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Isto porque, como já explicitado, foi encontrado em poder de relevante variedade de entorpecentes, em local reconhecido como ponto de tráfico de drogas. A melhor interpretação do artigo 33, §4º, é a de que o dispositivo é aplicável apenas ao chamado "traficante eventual" ou ao "traficante de primeira viagem" (Rel. Des. MARCOS ZANUZZI, TJSP/5ª Câmara, Apelação Criminal nº 1.098.7683.3/9 Limeira v.u. j. em 22.11.2007), o que, por óbvio, não se verifica no caso em exame. Nesse sentido: "(...) Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista n §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas(...)". (STJ, HC 373523 / SP HABEAS CORPUS 2016/0259708-7, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 14.08.2018). E não prospera a tese da ocorrência de bis in idem ao considerar a quantidade e variedade de drogas para fins de aumento da pena-base e para o afastamento da referida causa de diminuição de pena. Veja-se: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO(...). III - Outrossim, é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Precedentes". (HC 424437 / RJ HABEAS CORPUS 2017/0292125-2, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, em 06.02.2018). Com relação ao regime de cumprimento da pena, deverá ser estabelecido o fechado, sobretudo diante da gravidade concreta do crime praticado. Além do mais, incidiu o acusado em crime constitucionalmente equiparado a hediondo (artigo 5º, XLII, da Constituição Federal), a demonstrar que o Constituinte, ao assim prevê-lo, quis inserir na mais alta norma do ordenamento pátrio a previsão de tratamento mais enérgico àqueles que incorrem na referida conduta. Trata-se, assim, de evidente mandamento constitucional de natureza penal, consolidando a ideia de proteção eficiente a bens jurídicos consagrados pelo Direito pátrio. A concessão de tratamento mais benevolente - seja por regimes que não o fechado, seja pela concessão de penas restritivas de direitos - àquele que difunde inúmeros prejuízos à saúde pública, causando inestimáveis danos não somente à rede de atendimento, mas também aos núcleos sociais diversos, ofende frontalmente a dignidade da pessoa humana. Refletindo os argumentos expostos, o elucidador precedente deste Tribunal de Justiça: "(...) a fixação de regime mais brando não atenderia aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, levando-se em conta, como já mencionado, a personalidade do réu voltada ao delito, as circunstâncias e gravidade do crime, e o total de pena imposto. De modo contrário, injusta seria a situação daquele que pratica conduta menos gravosa, com condenação a pena mais branda, sujeito ao mesmo regime prisional daqueles que praticam crimes hediondos ou equiparados. Se assim não fosse, não teria sentido outro regime a ser fixado. O legislador, o que se observa na própria Constituição Federal (artigo 5º, inciso XLIII), ao tratar o traficante de drogas com o regiro necessário, até pelo fato de o delito ser equiparado a hediondo, negou-lhe vários benefícios que a outras espécies de criminosos seriam cabíveis (...). Portanto, seria contraditório que,

condenados, esses infratores recebessem pena alternativa ou cumprissem as reprimendas em regime diverso do fechado, não havendo que se falar em inconstitucionalidade." (TJSP; Apelação 0019747-87.2017.8.26.0050; Relator: Marco Antonio Marques da Silva; 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; j. 22/02/2018). Por fim, pelas mesmas razões já expostas, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do Código Penal, tratando-se de medida que é não socialmente recomendável no caso concreto. As circunstâncias em que cometido o delito revelam, inequivocamente, que a substituição não seria suficiente para atingir as finalidades de retribuição e prevenção da reprimenda. Não se pode olvidar, ainda, que se trata de um delito equiparado a hediondo e, portanto, de maior repugnância, gravidade e lesividade à sociedade. Destaca-se o entendimento consolidado no STJ: "TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à quantidade, à natureza e à diversidade da droga apreendida é motivação suficiente a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. Na hipótese dos autos, as circunstâncias em que ocorreu o delito, em especial o número de porções, e a nocividade do entorpecente apreendido, denotam que a medida substitutiva não se mostra socialmente recomendável, sendo, portanto, legítimo impedir a permuta pretendida pelo agravante (...)" (AgRg no AREsp 507029 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0092856-2, Min. Rel. Jorge Mussi, 5ª Turma, em 10.10.2017). Ante o exposto, requeiro a PROCEDÊNCIA da ação penal, para condenar o réu EMERSON OTTENIO DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O(a) Dr(a). Defensor(a), se manifestou através de áudio em sede de debates gravados por áudio e vídeo. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. EMERSON OTTENIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, em 21 de novembro de 2021, por volta das 13h54, na Rua Marcondes Machado, nº 3, Sapopemba, nesta Capital, teria fornecido e trazido consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 95 tubos de Eppendorf contendo cocaína na forma de crack, com peso líquido de 15,92 gramas, 18 papérolas de cocaína sólida, com peso líquido de 19,9 gramas, 24 tubos de Eppendorf contendo cocaína em pó, com peso líquido de 4,2 gramas, e 42 invólucros de maconha, com peso líquido de 156,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais). A denúncia foi recebida (fls. 68/70) e o réu apresentou resposta à acusação (fls. 167/179). O feito prosseguiu porquanto ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP. Designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 08/02/2022, foram ouvidas testemunhas de defesa e de acusação, interrogando-se na sequência o réu, que teve oportunidade de conversar, antes e em particular, com seu i. Defensor. Encerrada a instrução, o Ministério Público postula procedência integral da ação, pena-base acima do mínimo, indeferimento do redutor do §4º do art. 33, descontando-se a pena em regime fechado. A i. Defesa, por sua vez, sustenta a absolvição do acusado, tangenciando, na realidade, argumentos pertinentes à desclassificação do fato para enquadrá-lo no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pena mínima, redução máxima do art. 33, §4º, da referida legislação, regime aberto e substituição por restritivas de direito. Relatei sumariamente. Fundamento e DECIDO. A denúncia atende a todos os requisitos do art. 41 do CPP. A materialidade delitiva encontra-se adequadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação preliminar (fls. 28/29), laudo definitivo (fls. 194/197) e depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório. Igualmente comprovada a autoria delitiva. Com efeito, Marcos Tadeu de Moraes Pareschi, um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, recordou-se do réu presente na audiência. Estava em patrulhamento pela via quando avistou o acusado em

uma atitude suspeita (ele ficou um pouco assustado). Tratava-se de um local conhecido ponto de tráfico de drogas. Com ele, precisamente em seu bolso, foram apreendidos dinheiro e drogas. Ele portava um saquinho plástico dentro do qual estavam as substâncias proibidas. No bolso havia pinos de cocaína, porções de crack embalados para venda, bem como dinheiro em espécie. As porções estavam individualizadas. Informalmente, o acusado disse 'já era' e que falaria apenas em Juízo. Eram só as drogas, não havia instrumentos típico de uso. O depoente não conhecia o acusado. No mesmo sentido, o policial Leonardo Oliveira Santos. Afirmou recordar-se do réu presente em audiência. O depoente e seu companheiro Marcos avistaram EMERSON, que demonstrou nervosismo. Abordado, foram encontrados em seu bolso drogas e dinheiro. Tratava-se de maconha, crack e cocaína, tudo em pequenas porções. A droga estava dentro de um saco plástico, em embalagens individuais. Foi apreendido dinheiro, aproximadamente R\$ 79,00 trocados. A reação do réu no momento da captura foi dizer 'perdi, perdi' e que falaria apenas em Juízo. Não disse, em nenhum momento, que era usuário. Não se recordou se o réu portava algum instrumento tipicamente usado por usuários. Confirmou que o local da prisão é conhecido ponto de drogas. Negou conhecer o réu de outras ocasiões. Não havia outras pessoas no local. EMERSON vestia calça jeans. A sacola estava dentro do bolso da calça jeans. Dentro dessa sacola havia a droga. O policial não soube precisar o peso correlato, mas afirmou tratar-se de quantidade razoável, pois estava cheia. Em momento algum o réu apontou qualquer motivo para que os policiais forjassem um flagrante, não havendo o porquê de desconsiderar os depoimentos desses servidores públicos. Nesse sentido: 'APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pleitos objetivando: a) fixação da pena base acima do mínimo legal; b) afastamento da figura do tráfico privilegiado; c) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) fixação do regime inicial fechado. 1. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso. 2. Dosimetria da pena que merece reparo. 2.1. Pena-base fixada no limite mínimo. Pleito objetivando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga que não conferem maior reprovabilidade à conduta. 2.2. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. 2.3. Manutenção do regime inicial aberto. 2.4. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afastamento do caráter hediondo uma vez reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada. 3. Recurso conhecido e desprovido' (TJSP: Apelação Criminal 1501428-56.2021.8.26.0567; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairinque - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 07/02/2022). 'APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido na posse de substâncias variadas, nocivas e de nefastas consequências - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência - Validade - Desclassificação para uso - Não acolhimento - Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil - Pena alterada - Reduzido o percentual de majoração da pena de partida - Agravante de calamidade pública corretamente reconhecida - Redutor negado, mercê da comprovada reincidência - Regime mantido, em razão da reincidência e da gravidade concreta da conduta - Apelo parcialmente provido' (TJSP: Apelação Criminal 1509047-84.2021.8.26.0228; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 07/02/2022). 'APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Palavra dos policiais - Credibilidade -

Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Condenação acertada e mantida - Dosimetria penal - Redução da pena - Descabimento - Penas mantidas na minimidade embora reconhecida a menoridade relativa do réu (Súmula 231 STJ) - Aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Inadmissibilidade - Quantidade, natureza das drogas apreendidas e circunstâncias, demonstram dedicação às atividades criminosas - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Impossibilidade - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - APELO IMPROVIDO, com correção, de ofício, de erro material' (TJSP: Apelação Criminal 1500967-60.2020.8.26.0457; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 07/02/2022). Já as testemunhas arroladas pela i. Defesa não infirmaram, em momento algum, o alegado pelos policiais militares, tampouco presenciaram o aqui investigado, trazendo informações laterais e que, de qualquer modo, não induzem à absolvição. Com efeito. Darly de Souza Pinto conhece o réu há uns três anos e meio. Recorda-se do dia 20 de novembro de 2020, um sábado, data de comemoração do seu aniversário. O acusado esteve na festa de seu aniversário, no salão do prédio e na extensão das festividades em sua residência. EMERSON saiu de lá por volta de 6h da manhã, o sol já havia nascido. Todos os participantes fizeram uso de álcool. Desconhece qualquer envolvimento do réu com tráfico. Apenas sabe que ele é um usuário que sempre tentou se reabilitar, inclusive mediante internações. Depois da festa não soube dizer para onde ele foi, certamente bastante alterado pelo consumo de bebidas alcoólicas. Desconhece qualquer fato investigado nestes autos. Diego Costa Peres também conhece o acusado de longa data, há mais de dez anos, foram criados próximos. Desconhece qualquer envolvimento dele com crime organizado ou tráfico de entorpecentes. No sábado, dia 20 de novembro de 2021, esteve com EMERSON. Era aniversário da esposa do depoente. Fizeram uma festa no salão do prédio. O réu chegou algo em torno de 4 ou 5h da tarde e a festa se estendeu pela madrugada. Houve consumo de bebida alcoólica, inclusive por EMERSON. Saiu de lá por volta das 5 ou 6h da manhã. Não sabe para onde ele foi, saiu sem se despedir. Confirmou que o acusado é usuário de drogas há vários anos. Após períodos de sucesso, tem recaídas. Cláudia Ferreira Silva trabalha em um posto de gasolina. As imagens de segurança do estabelecimento no dia dos fatos foram apreendidas em uma operação policial. Os computadores, inclusive, foram levados. EMERSON era cliente assíduo do posto, principalmente em finais de semana. Ali, encontra-se com amigos, compram e consomem bebidas alcoólicas, sentam-se em uma mesa destinada a clientes. Não presenciou qualquer atitude suspeita de que o réu tenha envolvimento com crimes. Na data dos fatos, a depoente estava de folga. Ivan Carlos da Silva, por sua vez, é amigo de EMERSON desde a adolescência. Após breve afastamento, retomaram a amizade há uns três anos. O depoente apresentou a EMERSON um projeto funcional e os dois começaram a treinar com Ivan. O projeto foi uma ideia surgida quando todas as academias fecharam, no início da pandemia. O réu foi um dos incentivadores nesse trabalho. EMERSON trouxe outros amigos que não se viam há anos. A participação dele foi importantíssima, pois se trata de um trabalho boca a boca. Desconhece qualquer envolvimento do colega com o crime organizado. A prisão dele foi uma surpresa, relata. O réu usa entorpecente e o depoente já chegou a oferecer ajuda, frequentam igreja juntos. O projeto é localizado no Sapopembana. Lucas Rocha Batista, no dia 22 de novembro de 2021, esteve na companhia do réu no posto de gasolina referido por Claudia. Ficaram um tempo no local por volta das 10h da manhã. Consumiram bebidas alcoólicas juntos. Perto das 11h, o depoente foi embora. Quando Lucas saiu com o carro, EMERSON também o fez, mas não contou ao primeiro o destino. O acusado faz uso, é certo, de entorpecentes (cocaína). Desconhece a testemunha envolvimento dele com organizações criminosas. Perceba que os relatos das testemunhas de defesa não infirmam, de fato, o pontuado na denúncia, tampouco trazem um alibi favorável ao acusado (lembrando que o crime ocorreu no dia 21 de novembro de 2021, domingo, por volta das 14h). Vale ressaltar, por oportuno, que o réu não nega, em seu interrogatório, ter sido preso no local apontado pelos policiais militares, recusando-se a confessar somente a posse dos entorpecentes apreendidos. Em Juízo, EMERSON esclareceu que, naquele

fatídico dia, por volta das 11h, saiu do posto de combustíveis onde encontrara Lucas e decidiu buscar droga para seu consumo. Chegou a adquiri-la, sendo, depois, abordado por policiais militares. Ficou de fato nervoso, mas não estava com aquela grande quantidade de droga, das quais mantinha distância de cerca de cinco ou dez metros. Quanto ao dinheiro, havia uma nota de cinquenta reais. Nega que tenha corrido ou esboçado reação. Na abordagem, levantou as mãos e esperou a averiguação. Conseguiu comprar um papelote de cocaína. O traficante que

estava na parte de cima se evadiu por outro lado, embora ali, normalmente, ficam dois vendedores. Anote-se que o traficante, se logrou êxito fugir, poderia tê-lo feito com as drogas, até porque é sabido serem obrigados, muitas vezes, a ressarcir os respectivos fornecedores. Os policiais, no momento da abordagem, começaram a entrevistá-lo e, na sequência, acharam uma porção de cocaína em seu bolso. Não sabe dizer como apareceram com a outra droga. Entre o local da prisão e o local onde comprou a droga havia uma distância de dez ou quinze metros (o que, convenha-se, permitia a visualização pelos policiais militares de eventual outra pessoa, presença rechaçada pelo policial Leonardo). Nunca viu os policiais. Quando inquirido, não soube esclarecer algumas incongruências, reduzindo o valor do seu depoimento pessoal. Enfim, sua versão de que estaria no local apenas para adquirir maconha não se harmoniza aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas na posse do réu autorizam uma conclusão segura no sentido de que a posse do material se destinava à mercancia ilícita, mormente porque o acusado não soube esclarecer pontos e contradições essenciais em seu depoimento. O fato de ostentar bons antecedentes e boa formação não exclui, automaticamente, a acusação mais gravosa de tráfico. Também o fato de ser usuário de entorpecentes não afasta que, na ocasião, estivesse traficando, ainda que com o objetivo de auferir recursos para sustentar o vício. É elogiável sua atuação como cofundador de um projeto social que, segundo a i. Defesa, visa estimular a prática de esportes para pessoas de todas as idades e níveis sociais. Porém, respeitado o posicionamento em contrário, não serve de alibi à imputação registrada na denúncia. Certo é que, e isso é isento de dúvidas, o acusado fora preso em flagrante em conhecido ponto de tráfico de drogas, portando os estupefacientes mencionados na incoativa, distribuídos em sacola. Ainda que o réu não seja flagrado vendendo drogas, o simples ato de possuí-las com o fim de comercialização é suficiente à materialização fenomênica do tipo penal. Quanto às testemunhas de defesa, notadamente a Sra. Cláudia, não afirmou que, no dia e horário especificados na denúncia, o réu estava no local dos fatos. Esse depoimento e os demais, inclusive o de Lucas, como a própria i. Defesa afirma à fl. 172, atestam acontecimentos anteriores à prisão, sendo incontroverso que o réu se dirigira ao ponto de venda de entorpecentes (e lá fora preso). Além das testemunhas de Defesa não terem presenciado os fatos, é incontroverso que EMERSON se encontrava no local da prisão. Só não é quanto à imputação de portar todos os estupefacientes apreendidos. E, nesse caso, os policiais militares foram uníssonos no sentido de da procedência da denúncia, policiais cuja credibilidade não por infirmada. Eventuais e pequenas imprecisões entre os depoimentos extrajudiciais e judiciais não prejudicam a validade dos depoimentos, mormente diante da quantidade de prisões e apreensões realizadas diuturnamente por policiais militares, seja pelo tempo decorrido. Não houve, diferentemente do sustentado pela i. Defesa, mudança substancial entre as versões. Vale acrescentar, quanto à prova documental, que o contrato de fls. 180/183 é antigo (data de 2008). Mesmo assim, não se nega que o acusado seja usuário, situação compatível também com a acusação de tráfico no caso concreto aqui investigado. Por fim, a prova dos autos conduz à procedência da ação mesmo se se desconsiderar qualquer confissão informal aos policiais no momento da prisão flagrancial. Dessa forma, comprovado o comportamento enquadrado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, resta a quantificação da reprimenda. Considerando a quantidade expressiva e a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos [fls. 22/23, 26/29 e 194/197 – 95 tubos de Eppendorf contendo cocaína na forma de crack, com peso líquido de 15,92 gramas; 18 papelotes de cocaína sólida, com peso líquido de 19,9 gramas; 24 tubos de Eppendorf contendo cocaína em pó, com peso líquido de 4,2 gramas; 42 invólucros de maconha, com peso líquido de 156,1 gramas], a pena

base deve ser fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, entendendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa. Sem atenuantes. A pena permanece em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na fase derradeira, aplica-se o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual '... as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa'. O réu é primário (certidão de fl. 35) e possui bons antecedentes. A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, para fins de aplicação, ou não, do redutor, devem ser analisadas cum grano salis. Há situações extremas nas quais a enorme quantidade de drogas encontrada permitiria uma conclusão juridicamente segura no sentido de que a traficância se dá em grande escala. Não é, definitivamente, esse o caso dos autos. Dessa forma, a situação de EMERSON caracteriza-se mais como de pequena traficância, afastando a tese de dedicar-se a atividade ou organização criminosa. Embora exista divergência jurisprudencial quanto ao tema, comungo do entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci, para o qual 'a quantidade de drogas, mesmo volumosa, no campo abstrato, não impede a aplicação do redutor, impondo-se a diminuição da pena. Não se pode deduzir que, em tese, por haver quantidade expressiva, o acusado está envolvido com o crime organizado ou se dedique a atividades criminosas, razão pela qual impediria o redutor. Excepcionalmente, no entanto, uma quantidade anormal de drogas pode indicar a participação em grupo criminoso e essa circunstância deve resultar das provas inerentes ao processo. Enfim, cada caso é um caso' (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, volume 1, 14ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2021, p. 409). Nesse diapasão, é caso de aplicar o redutor em seu máximo (2/3), à míngua de elementos outros que não o recomendariam em grau inferior. Reforça essa linha de análise a sinalização do E. Tribunal de Justiça no sentido de aplicar, ao caso em exame, o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Torno definitiva a pena equipolente a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Considerando não haver prova de o réu possuir elevada capacidade econômica, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, que será atualizado monetariamente desde então (art. 49, §2º, do Código Penal). O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o aberto, de acordo com o art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal. Prejudicada no caso em apreço a incidência do art. 387, §2º, do CPP. Presentes todos os pressupostos objetivos (quantidade da pena; primariedade do agente; não utilização de violência ou grave ameaça na consecução da infração) e subjetivos [a culpabilidade em sentido lato (nada há nos autos que indique grau anormal de reprovação que não tenha sido já considerado pelo legislador penal), os antecedentes (favoráveis, a despeito da condenação não transitada em julgado; v. fundamentação da terceira fase de aplicação da pena; v. também STJ, súmula 444), a conduta social (nada se sabe de negativo acerca do papel do réu na comunidade em que vive) e a personalidade do condenado (nada consta de negativo), ausente qualquer motivo ou circunstância contrária à substituição, reputo necessária, adequada e proporcional em sentido estrito a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, §2º): prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana. No primeiro caso, a sanção alternativa permite ao apenado reparar, por meio do trabalho lícito, o dano causado à sociedade. Já a limitação de finais de semana justifica-se no fato de o réu ter o compromisso frequente de participar de cursos e palestras importantes para sua reabilitação, distanciando-o, por algumas horas dos finais de semana, de eventuais más companhias. CONCLUSÃO Diante de todo o exposto, julgo procedente a ação penal formulada em face de EMERSON OTTENIO DA SILVA, qualificado nos autos. Em consequência, condeno-o pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10

(dez) dias de reclusão em regime aberto, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no valor individual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, o que será atualizado monetariamente desde então. Ressalvando-se o art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal, fica a privação de liberdade substituída por duas restritivas de direito, que serão detalhadas pelo r. Juízo das Execuções (artigos 147 e 148 da Lei nº 7.210/84): prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana. Declaro o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido com o réu, revertendo-o ao FUNAD, comunicando-se oportunamente (art. 63 e parágrafos da Lei nº 11.343/2006; art. 481-A das Normas; ADPF 569/DF). Ressalvada a manutenção de amostras para pelo menos mais dois eventuais exames de contraprova, nos termos dos artigos 524 e 524-A das NJCGJ, caso ainda não se tenha

determinado, fica autorizada a destruição das drogas apreendidas. O réu arcará com as custas previstas no art. 4º, §9º, alínea 'a', da Lei Estadual nº 11.608/2003. A custódia cautelar é incompatível tanto com o regime aberto, quanto com as sanções alternativas. Daí o porquê de autorizar o recurso em liberdade. Oportunamente, providenciem-se as comunicações de estilo, notadamente as previstas nos artigos 393, inciso V e 398, inciso II (TRE); ambos das NJCGJ. Quanto à pena de multa cumulativamente aplicada, proceda-se na forma do seu art. 480. Registre-se. Intimem-se". Após lida a sentença, o Ministério Público, a Defesa e o(a) ré(u) manifestaram interesse em não recorrer. Com efeito, o(a) ré(u) sai devidamente intimado(a) da condenação e do pagamento da multa, cujo valor deverá ser solicitado pelo réu por email ao cartório (sp10cr@tjsp.jus.br) no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o qual começará a fluir o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento, sob pena de ter o seu nome inscrito na dívida ativa do Estado. Ainda, caso o pagamento da referida multa não seja efetuado no prazo de 10 dias do trânsito em julgado da presente decisão, expeçam-se certidões e ofício à Procuradoria da Secretaria da Fazenda - Setor - EX_CI, encaminhando-se as peças necessárias para inscrição da dívida. Após revisados os autos, ao arquivo. Saem os presentes cientes. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário).

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 16 de fevereiro de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.